

RECURSO CÍVEL Nº 5006316-26.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOEDES DA SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS E APBRASIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DO INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO INSS À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação subsidiária da autarquia previdenciária à reparação dos danos materiais. Fica mantida a condenação à indenização dos danos morais. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 28 de janeiro de 2025.

5006316-26.2024.4.02.5006

500003500621 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5006316-26.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOEDES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido em ação que versa sobre fraude na autorização de descontos em folha a título de contribuição confederativa e os danos dela decorrentes.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"Trata-se de ação ajuizada por JOEDES DA SILVA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL, objetivando a suspensão de descontos em seu benefício a título de contribuição associativa, a restituição das parcelas já descontadas, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

Dispensado o relatório conforme preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01.

Fundamento e decido.

Da Prescrição

Quanto à prescrição, o termo inicial é a data da lesão ou pagamento, que ocorre por ocasião do último desconto no contracheque. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

Portanto, no caso concreto, não há que falar em prescrição, uma vez que os descontos mensais ainda estavam sendo realizados mensalmente quando do ajuizamento da presente ação.

Assim, afasto a preliminar de mérito alegada.

Da Ilegitimidade Passiva do INSS e Incompetência da Justiça Federal

Preliminarmente, destaco que, quanto à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do INSS, tenho que a mesma não merece prosperar, pois a mesma é responsável, como conveniente, pelos descontos, na medida em que deve zelar, em atenção ao princípio da eficiência, para que fraudes não ocorram, ou seja, é responsável por fiscalizar a regularidade do cadastramento das entidades junto ao seu sistema e das consignações realizadas.

Definida a legitimidade do INSS para responder a presente ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para dirimir a lide.

Do Mérito

A ré A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL, devidamente citada, não apresentou contestação. Assim, decreto a revelia da mesma, o que induz à incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do que dispõe o artigo 344 do CPC/2015. Trata-se, todavia, de presunção relativa, que deve estar amparada por elementos probatórios aptos a dar o suporte necessário à aplicação da ficção legal.

Alega a parte autora, em suma, que verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente a contribuição associativa - CONTRIBUIÇÃO AP BRASIL SAC 08005915092, que alega desconhecer.

Não se pode olvidar que, ao caso, se aplica a responsabilidade objetiva, decorrente do exercício pelas rés de atividade de risco, na forma como estabelecida no parágrafo único do artigo 927 do CC/02, porquanto se procede a pagamento de benefícios previdenciários, consentindo com recolhimentos de contribuições associativas.

Necessário ressaltar que, diante da ausência de relação de consumo, não se aplica a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC. Justamente por isto, não há como afastar o dever de máxima diligência decorrente desta atividade.

No tocante ao INSS, aplica-se ainda o regime da responsabilidade civil objetiva em função da teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). Como agente pagador, é seu dever diligenciar para que não ocorram fraudes, ou, ao menos, agir de molde a inibir a sua incidência, em atenção ao princípio constitucional da eficiência que rege a Administração Pública, o que não foi o caso dos autos, uma vez que não foi apresentada em sua peça de defesa nenhuma prova de que assim procedeu.

O dispositivo legal supracitado refere-se à cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, fundamentada pelo risco da atividade desempenhada. Ao realizar descontos em vencimentos ou proventos que não foram subscritos pelos segurados, incorre a autarquia ré em gravíssima mácula ao dever de vigilância, segurança e diligência a ela perfeitamente imputáveis.

Por sua vez, a segunda ré, devidamente citada, sequer manifestou-se nos autos.

Sendo assim, a A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL não se desincumbiu do ônus da prova (art. 14, §3º, II, do CDC e art. 373, II, do CPC), não tendo apresentado qualquer prova de que a filiação à associação foi efetivamente contratada pela parte autora. Tal diligência constitui ônus processual da parte requerida, de forma que, não sendo por ela observada, operar-se-á a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora em sua peça inicial, nos termos do artigo 400 do CPC.

Neste sentido, não se pode olvidar que é de conhecimento geral os inúmeros casos desta natureza, e em razão disto, já se deveria ter adotado medidas inibitórias à ocorrência de fraudes como esta, o que não ocorreu.

Sendo assim, devem cessar os descontos que vêm sendo efetuados e, além disso, uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, exsurge o dever de reparar o dano sofrido, material e moral.

O dano material se consubstancia nos valores que foram descontados dos proventos da autora referentes a essas mensalidades associativas, a ser efetivamente apurado na fase executiva do procedimento.

Em relação ao dano moral, considerando a natureza alimentar da verba de que a parte autora ficou privada, em razão de falha na conduta da associação, impõe-se a esta o dever de arcar com a compensação por dano moral. De fato, a subtração inadvertida de parte de rendimento de natureza alimentar não constitui mero dissabor cuja tolerância seja exigível. Cuida-se de fato causador de abalo moral injusto, merecedor de reparação.

Na hipótese, o dano moral ocorre in re ipsa, devendo ser reconhecido, em razão de uma presunção oriunda da experiência normal. Afinal, nenhuma pessoa deixa de se sentir abalada, sendo privada injusta e inadvertidamente, de parcela da verba destinada a seu sustento e o de sua família. Nesse contexto, o que se presume não é o fato deflagrador do dano extrapatrimonial (este suficientemente comprovado nos autos), mas a aptidão deste fato para deflagrar as lesões de ordem moral.

Mas a indenização por dano moral não é fonte de enriquecimento. O valor da reparação deve ser estimada de modo prudente, com a necessária sensibilidade para a extensão do dano causado e a gravidade da ação culposa, atentando-se, em especial, para a finalidade voltada a dissuadir o causador do dano a não repetir o ato que o provocou.

Nessa linha de raciocínio, merecem compensação os danos causados ao patrimônio moral da parte autora, sendo que arbitro a indenização em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), valor razoável e proporcional, suficiente para compensar a vítima pelo dano causado e desestimular a reincidência em condutas desta natureza.

Registre-se que a responsabilidade do INSS, no presente caso, é subsidiária, isto é, somente poderá ser executado o título judicial (após o trânsito em julgado) em face da autarquia caso frustrada a execução em face da associação corré.

Da Tutela provisória

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter

alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado. Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS cesse o desconto mensal no benefício previdenciário da parte autora.

Dispositivo.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido formulado na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

I - **Declarar** a inexistência de débito da parte autora para com a associação em relação à contribuição associativa discutida nos presentes autos;

II - **Condenar** a associação, a devolver todos os valores que foram indevidamente descontados dos proventos da parte autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a pagar, a título de compensação por dano moral, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

III - **Reconhecer** a responsabilidade subsidiária do INSS pelo pagamento dos valores da condenação.

CONCEDO a tutela provisória de urgência, devendo ser intimada a CEABDJ para que cesse, em definitivo, o desconto mensal com comprovação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento.

Decreto a revelia da A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL.

Os valores deverão ser atualizados aplicando-se **juros moratórios e correção monetária** calculados com base nos índices oficiais do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1º da Lei 10.259/2001).

(...)"

Recorre o INSS aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência da Justiça Federal após sua exclusão da lide. Suscita a prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argui a inexistência de ato ilícito e de vantagem financeira da autarquia; a inexistência de nexo causal; e a culpa exclusiva de terceiro. Reafirma que as quantias descontadas em folha de pagamento foram integralmente repassadas à CONAFER, única responsável pela restituição e pela indenização dos danos morais. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a natureza subsidiária da responsabilidade da autarquia.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** - Tema 326). Todavia, **não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática nas instâncias ordinárias.** Por esse fundamento, inexistem óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuar-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição há reconhecer no caso concreto.

No mérito, reputo necessário estabelecer algumas premissas anteriormente a análise das demais alegações recursais:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é restrita ao âmbito das relações de consumo, em que se visualiza a existência das figuras do consumidor (artigo 2º do CDC) e do fornecedor de produtos ou serviços (artigo 3º do CDC).

Ocorre que o INSS é uma autarquia e, como tal, desempenha atividade típica de Estado, a ele se aplicando o mesmo regime imposto à Fazenda Pública, atuando sem qualquer interesse econômico ou comercial, buscando, apenas, a consecução do interesse coletivo.

Desse modo, sendo a relação do segurado com o INSS uma relação previdenciária e de caráter público, não haveria mesmo falar em aplicação do CDC a este caso concreto.

Além disso, destaco que, a despeito das divergências, entendo que nem mesmo às associações, em hipóteses como a vertente, se aplica o CDC.

Ora, as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, nos termos do que dispõe o artigo 53 do CC. Logo, o associado integra a associação, detendo, inclusive, direito de voto, sendo certo que esta não desenvolve atividade empresarial lucrativa, razão pela qual não se enquadrariam as funções de associação e associado nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados no CDC.

É certo que, no caso dos autos, o autor não é associado, sendo esta justamente a questão discutida na lide. Ocorre que, ainda assim, não haveria propriamente uma relação de consumo, mas sim uma relação privada, em que o suposto causador de danos deve responder pelos prejuízos e danos causados à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

"(...) o o Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente

aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..."REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)

Como esclarecido acima, não há falar em aplicação do CDC à lide e, da mesma forma, não há como se reconhecer a solidariedade por eventual reparação de danos entre o INSS e a associação, vez que não há relação de consumo (artigo 7º, parágrafo único, do CDC).

Contudo, tampouco haveria falar em solidariedade por qualquer outro fundamento. Nos termos do artigo 264 do Código Civil, "*há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda*".

Ocorre que as relações do segurado com o INSS e do pseudoassociado com a associação são distintas e, portanto, também geram obrigações distintas e independentes. Isso a começar porque diante da prática de atos ilícitos, respondem a autarquia e associação por fundamento normativo diverso.

Além disso, há que se ressaltar que a entidade pública demandada não pode responder pelos valores indevidamente descontados pela associação a título de danos materiais, vez que destes não se beneficia.

Considerando que o proveito econômico dos descontos indevidos em benefício previdenciário foi revertido única e exclusivamente em favor da APBRASIL, natural que somente a esta seja condenada à reparação dos danos materiais.

Sendo assim, **afasto a condenação do INSS à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, mesmo que em caráter subsidiário.** Fica a condenação, portanto, restrita à APBRASIL.

Os danos morais, por sua vez, restam perfeitamente configurados, dada a falta de cuidado/diligência do INSS, que, apesar de ter a obrigação de zelar pela integridade da folha de pagamento dos segurados, permitiu fosse consignada contribuição facultativa benefício previdenciário de natureza alimentar sem trazer aos autos o documento relativo à autorização expressa da recorrida para fazê-lo.

Sendo assim, a condenação da autarquia previdenciária à indenização dos danos morais deve prevalecer.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação subsidiária da autarquia previdenciária à reparação dos danos materiais. Fica mantida a condenação à indenização dos danos morais. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.